

# TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

## LEGISLACIÓN I



# TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

## UNIDAD 1 EL DERECHO

## UNIDAD 1: EL DERECHO

*"Para algunos, lo que es de derecho es lo que es justo; otros afirman la independencia mutua de la justicia y el Derecho, y otros, finalmente, llegan a subordinar al Derecho la justicia, sosteniendo que algo es justo porque se ajusta al Derecho".<sup>1</sup>*

### PRESENTACIÓN

La presente materia se encuentra orientada a la introducción del alumno en el análisis del fenómeno jurídico a partir de las diferentes nociones existentes respecto del concepto del Derecho.

A partir de esta primera aproximación, se repasarán los conceptos de Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo, para luego entrar en la distinción entre Derecho y Moral, por último analizar los Principios Generales del Derecho y su función en el marco del ordenamiento jurídico de cualquier Estado.

Seguidamente, se verá el ordenamiento jurídico y su funcionamiento como sistema, su unidad y jerarquía. También se analizará específicamente la pirámide jurídica de Hans Kelsen.

Por último, se entrará en el análisis de los conceptos de Derecho Público y Derecho Privado, y las diferentes visiones del mundo jurídico de las corrientes iuspositivistas y iusnaturalistas.

### OBJETIVOS

### QUE LOS PARTICIPANTES:

---

<sup>1</sup> FERRATER MORA, José; Diccionario de Filosofía, 5º ed., Ed. Sudamericana, Bs. As., Tomo I, 1964, pág. 421.

- Comprendan nociones básicas del fenómeno jurídico.
- Entiendan que no existe una noción inequívoca del concepto del Derecho.
- Aprendan las diferencias existentes entre Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo, y entre el Derecho Público y el Derecho Privado.
- Incorporen los elementos esenciales para diferenciar las distintas corrientes del pensamiento ius filosófico.
- Conozcan la noción del ordenamiento jurídico, su estructura y jerarquía.

## TEMARIO

**1. El Derecho: concepto. Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo. Derecho y Moral. Los principios generales del Derecho.**

**2. El ordenamiento Jurídico: concepto. Sistema, unidad y jerarquía. El Estado y el Derecho. La pirámide jurídica de Kelsen: Constitución Nacional, normas generales y normas individuales.**

**3. Las ramas del Derecho: Derecho Público y Derecho Privado; Derecho Natural -iusnaturalismo- y Derecho Positivo -iuspositivismo-.**

### **1. El Derecho: concepto. Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo. Derecho y Moral. Los principios generales el derecho.**

Dentro de la Ciencia Jurídica o de la Filosofía del Derecho todo concepto o definición de derecho lleva consigo un fuerte contenido axiológico -de valores-, aún cuando la posición sea justamente la negación de la existencia de valores dentro del Derecho –posición de Hans Kelsen-. Esto significa que dicha definición estará orientada a una visión del derecho según los valores de quien expresa el concepto.

Antes de avanzar sobre el concepto de Derecho, se debe realizar una aclaración respecto de los dos puntos de vista que puede tener el Derecho. Así, desde un punto de vista se encuentra el **Derecho Objetivo**, que hace referencia a los conjuntos o

grupos de normas jurídicas; y desde el otro, el **Derecho Subjetivo**, referido a la manera individual que se pone en ejercicio el derecho, es decir, es la prerrogativa, poder o facultad que inviste a una persona para reclamar el cumplimiento de las normas jurídicas que lo tutelan.<sup>2</sup>



En otras palabras, desde el punto de vista objetivo se refiere al ordenamiento jurídico o un sector de este, y desde un punto de vista subjetivo es la práctica o el ejercicio de un derecho.

Existen tantas definiciones o conceptos del Derecho como autores que han analizado el fenómeno jurídico. Esto implica que no existe una respuesta única y correcta respecto al concepto de Derecho, sino mejores o peores definiciones de dicho concepto.

Desde la primera versión de la Teoría **Pura del Derecho de Hans Kelsen** se sostiene que este autor identifica el Derecho a la Norma Jurídica, es decir, estudiar el fenómeno jurídico es lo mismo que estudiar la Norma.<sup>3</sup> No obstante, el pensamiento de Kelsen fue evolucionando a lo largo del tiempo, y en su obra **Teoría General del Derecho y del Estado** se refiere al concepto en los siguientes términos: "El derecho es un orden de la conducta humana. Un 'orden' es un conjunto de normas. El derecho no es, como a veces se dice, una norma. Es un conjunto de normas que tienen el tipo de unidad a que nos referimos cuando hablamos de un sistema".<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 16.

<sup>3</sup> KELSEN, Hans; Teoría Pura del Derecho, Traducción 2° ed. del alemán Roberto J. Vernengo, 2° reimpresión, México, 1982.

<sup>4</sup> KELSEN, Hans; General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945; traducción de E. GARCÍA MAYNEZ, Teoría General del Derecho y del Estado, Ed. UNAM, México, 1979, pág. 3.

Desde otro punto de vista, la **Teoría Ecológica de Carlos Cossio** sostiene que el fenómeno jurídico forma parte de una Ciencia Cultural y que el Derecho es la conducta humana en interferencia intersubjetiva.<sup>5</sup>

En cambio, para la **concepción realista del Derecho** -iusnaturalismo de raíz teológica- el concepto del Derecho gira alrededor de la idea de justicia -lo justo-. Así, **Rodolfo Vigo** señala que "El Derecho es propiamente lo justo debido por alguien a favor de otro, por necesidad legal y con estricta igualdad".<sup>6</sup>

En un sentido similar, con énfasis en la idea de justicia, **Guillermo Borda** lo define "(...) al Derecho como el conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conformes con la justicia"<sup>7</sup>. En cambio, una definición que hace hincapié en el bien público, es la de **Agustín Basave Fernández del Valle** quien sostiene que "el Derecho es una regla de vida social, una ordenación positiva y justa establecida por la autoridad competente en vista del bien público temporal".<sup>8</sup>

Por su parte, para **Immanuel Kant** "el Derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede armonizarse con el arbitrio de los demás según una ley universal de libertad", y esta ley dice: "obra externamente de tal manera que el libre uso de tu arbitrio pueda armonizarse con la libertad de los demás según una ley universal".<sup>9</sup>

Por último, se pueden mencionar dos definiciones más abarcativas del fenómeno jurídico, que incluyen o destacan el aspecto coactivo del Derecho. La primera, es la de **Eduardo García Máñez**, quién señala que el "Derecho es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas - integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible- son normalmente cumplidas por los particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder público"<sup>10</sup>. La segunda, es la de Aftalion, Vilanova y Raffo, quienes sostienen que el Derecho "es una forma de control social compuesta

---

<sup>5</sup> Cfr. COSSIO, Carlos; La Teoría Ecológica del Derecho y el concepto jurídico de libertad; Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1964.

<sup>6</sup> VIGO (h), Rodolfo; Visión Crítica de la Historia de la Filosofía del Derecho, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 1984, pág. 16.

<sup>7</sup> BORDA, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 1999, pág. 13.

<sup>8</sup> BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, Agustín; Filosofía del Derecho, Ed. Porrúa, México, 2001, pág. 21.

<sup>9</sup> KANT, Immanuel; Metafísica de las costumbres - Introducción a la doctrina del Derecho, Apartado B, BI, pág. 230.

<sup>10</sup> GARCÍA MÁÑEZ, Eduardo; Filosofía del Derecho, 17° ed., Ed. Porrúa, México, 2009, pág. 135.

básicamente de normas coercibles, vale decir, por reglas cuyo cumplimiento puede ser logrado por el uso de la fuerza".<sup>11</sup>

### - Derecho y Moral.

El punto de partida para el análisis del Derecho es la conducta humana, es decir, los actos de los hombres. Esta conducta puede ser analizada desde dos enfoques diferentes: el moral y el jurídico. Según sea el prisma a través del cual se analice la conducta, se estará en el campo de la moral o del derecho.<sup>12</sup>

El criterio para distinguir la conducta entre estas dos especies ha sido explicitado por **Giorgio Del Vecchio**, cuando señala que el Derecho reside en la interferencia intersubjetiva de la conducta humana<sup>13</sup>. Entonces, cuando el análisis de la conducta humana quede en el campo subjetivo de la conciencia del sujeto -sin materializarse en el campo externo- se está en el plano moral (fuero interno del sujeto). "Por eso, la moral es una manera subjetiva y unilateral de conceptuar, valorar y comprender la conducta"<sup>14</sup>. En cambio, el Derecho se ocupa de la conducta humana en interferencia intersubjetiva, lo que implica que para hablar de derecho debe analizarse la conducta humana del sujeto en relación a otro sujeto (fuero externo del sujeto).

Por su parte, Kant distingue la moral del Derecho en la diferencia de los *motivos del obrar*, denominados *acciones internas*, y el *aspecto físico* del obrar, denominado *acciones externas*. De esta forma, la moral sólo se refiere a los motivos del obrar del sujeto, a su fuero interno; en cambio, el Derecho se refiere sólo al aspecto externo de los actos, es decir, la conformidad de la acción del sujeto con la ley prescindiendo de los motivos.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 16.

<sup>12</sup> Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 383-386.

<sup>13</sup> DEL VECCHIO, G., Filosofía del Derecho, Tomo I, Ed. Bosch, Barcelona, 1936, pág. 2, 396, 403 y 412.

<sup>14</sup> Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 386.

<sup>15</sup> Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 389.

## **- Los Principios Generales del Derecho.**

El Código civil de Napoleón -1804- pretendió circunscribir en su cuerpo normativo la regulación de todos los aspectos de las relaciones jurídicas civiles, brindando “todas” las respuestas o soluciones jurídicas. En razón de esto, no contenía disposición alguna respecto de fuentes subsidiarias ante silencio o insuficiencia de la ley, omitiendo cualquier referencia a figuras jurídicas tales como los principios.

La primera introducción de los principios como fuente subsidiaria en un cuerpo normativo se origina con la sanción del Código civil austríaco -1811-. El artículo 7º incorporó expresamente los “principios del derecho natural”, habilitando al juez a recurrir a estos a fin de resolver casos dudosos ante la insuficiencia del texto legal.<sup>16</sup> Este mismo término fue incorporado por la Comisión Redactora al proyecto originario del Código Albertino de los Estados sardos para los casos dudosos, eligiéndose esta fórmula por sobre las otras propuestas: principios de razón, principios de equidad, principios de equidad natural, principios de razón natural, etc. No obstante, la propuesta definitiva del texto legal incorporó la expresión de “principios generales del derecho” en lugar de “principios del derecho natural”, y sin mayores debates ni discusiones, paso a ser el término utilizado en el Código Albertino -1837-.<sup>17</sup> Luego, continuaron con esta locución, los Códigos Civiles de Italia -1865-, Argentina -1869-, España -1888-, México -1928-, y Venezuela -1942-.<sup>18</sup>

Más allá de su recepción normativa en los códigos de fondo, los principios generales del derecho son pilares del ordenamiento jurídico, sin los cuales éste carecería de entidad vivencial, no existiría<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Artículo 7º, Código civil austríaco: “(...) cuando el caso permanezca aún dudoso, deberá decidirse según los principios del Derecho natural, teniendo en cuenta todas las circunstancias del mismo, cuidadosamente consideradas y pesadas”.

<sup>17</sup> Cfr. DEL VECCHIO, Giorgio; *Los Principios Generales del Derecho*, traducción de Juan Ossorio Morales, Librería Bosch, Barcelona, año 1933, págs. 6 y 7. El ministro de Justicia de la época había defendido la utilización de la locución “principios del derecho natural”, definiéndolos como “el conjunto de aquellas máximas de sana moral que son por todos reconocidas” (*Ibid*, pág. 7).

<sup>18</sup> Cfr. VIGO (h), Rodolfo L.; *Los principios jurídicos*, Depalma, Bs. As., 2000, pág. 81.

<sup>19</sup> Cfr. COVIELLO, Pedro J., “El control judicial de la discrecionalidad administrativa”, en “Control de la Administración Pública”, ediciones RAP, pág. 627, 642.





Los principios jurídicos son “una condensación de los grandes valores jurídicos materiales que constituyen el *substratum* del Ordenamiento y de la experiencia reiterada de la vida jurídica”<sup>20</sup>.

Los principios jurídicos *-stricto sensu-* conforman aquella parte del derecho con *status per se*, por sí mismo; es decir, es derecho por su propio contenido intrínseco y no porque así haya sido definido por alguna autoridad -en cualquiera de sus manifestaciones-.<sup>21</sup> Justamente, desde la perspectiva de “[...] los principios se puede ‘medir’ o ‘regular’, en términos de corrección jurídica, conductas y normas”.<sup>22</sup>

La visión de los principios varía según la visión que se tenga del concepto de Derecho. En este sentido, **Giorgio Del Vecchio**, representante del positivismo jurídico, entiende a los principios jurídicos como normas de carácter ideal, absoluto y extraterritorial, derivados de la razón humana; pero subordinadas al derecho positivo en función de la seguridad jurídica. En este sentido, señala el requisito de inexistencia de incongruencia entre ley y principios, para la validez de estos últimos. Por último, establece para la aplicación de los principios jurídicos en un caso concreto el siguiente procedimiento: primero se debe contemplar la ley; luego, ante inexistencia de norma regulatoria, se debe considerar a la analogía; y por último, ante la ausencia de los dos elementos anteriores, se aplican los principios generales del derecho.<sup>23</sup>

En cambio, desde otra óptica, se encuentra la postura de **Ronald Dworkin**, quien en su crítica al positivismo jurídico, sostiene la existencia en el sistema jurídico dotado de normas y principios jurídicos, permitiendo estos últimos, la existencia de una

---

<sup>20</sup> GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 7º ed., Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 463.

<sup>21</sup> Cfr. VIGO (h), Rodolfo L.; Los principios..., *op. cit.*, pág. 28.

<sup>22</sup> VIGO (h), Rodolfo L.; Los principios..., *op. cit.*, pág. 30.

<sup>23</sup> Cfr. DEL VECCHIO, Giorgio; Los Principios Generales del Derecho, traducción de Juan Ossorio Morales, Librería Bosch, Barcelona, año 1933.

única respuesta correcta en todos los casos aún ante la falta de norma positiva que regule la cuestión.<sup>24</sup>

## **2. El ordenamiento Jurídico: concepto. Sistema, unidad y jerarquía. El Estado y el Derecho. La pirámide jurídica de Kelsen: Constitución Nacional, normas generales y normas individuales.**

Se entiende por ordenamiento jurídico al conjunto de Principios, Valores y Normas Jurídicas que regulan la conducta humana en interferencia intersubjetiva en un determinado territorio.

También respecto a este concepto existen diferentes posiciones. Por ejemplo, para la "Concepción Normativa del Derecho" el ordenamiento jurídico sólo se refiere al conjunto de normas positivas. En esta corriente de pensamiento se encuentra Hans Kelsen<sup>25</sup> y H.L.A. Hart<sup>26</sup>.

En cambio, para la corriente de pensamiento iusnaturalista, además de las normas jurídicas debe considerarse conformado por el Derecho Natural, los Principios Generales del Derecho y los valores. En un sentido similar, se encuentra la posición de la corriente neoconstitucionalista, que resalta la inclusión al ordenamiento jurídico de los valores mediante su incorporación expresa o implícita en la Constitución -Carta Magna-.

### **- Sistema, Unidad y Jerarquía.**

Más allá de las diferentes concepciones del ordenamiento jurídico, todo orden jurídico tiene cierta estructura organizativa.

---

<sup>24</sup> Cfr. DWORKIN, Ronald; Los derechos en serio, traducción de Marta Guastavino, 5º reimpresión, Ed. Ariel S.A., Barcelona, año 2002.

<sup>25</sup> KELSEN, Hans; Teoría General del Estado, traducción de Luis LEGAZ LACAMBRA, Ed. Nacional, México, 1965, pág. 21/24, 299 y ss.; Teoría General del Derecho y del Estado, traducción de Eduardo GARCÍA MAYNEZ, Ed. Universidad Autónoma de México, México, 1988, pág. 129 y ss.; y Teoría Pura del Derecho, traducción de Roberto J. VERNENGO, Universidad Autónoma de México, México, 1979, pág. 285 y ss.

<sup>26</sup> HART, H.L.A.; El Concepto de Derecho, traducción de Genaro R. CARRIO, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1977, pág. 125 y ss.

Las normas y principios que componen el orden jurídico se interrelacionan entre sí de diferentes formas: algunas comparten un "mismo plano jerárquico", y otras están en un "plano de subordinación" respecto de normas de un "grado superior".

Las normas y principios que se encuentran en la cúspide del orden jurídico, determinan el contenido, la forma y el procedimiento para la creación de las normas de grada inferior. De esta forma, cada norma del sistema debe encontrar su fundamentación en las normas de grada superior del orden jurídico.

La fundamentación de las normas del ordenamiento jurídico tiene dos variantes: una formal, y otra, material. La fundamentación formal implica que la norma jurídica sea creada por el órgano competente para hacerlo, cumpliendo con los procedimientos previstos por una norma superior. En cambio, la fundamentación material hace referencia al contenido de la norma, y su no contradicción con los contenidos de las normas de "grada superior".



"Cada norma, para integrar válidamente el sistema, debe ser creada por un órgano competente mediante los procedimientos previstos en una norma superior y con contenidos que no contradigan a los contenidos prescriptos en normas superiores. El órgano y los procedimientos brindan la fundamentación formal, los contenidos la fundamentación material."<sup>27</sup>

En definitiva, el conjunto de normas y principios integra un "sistema normativo" en el cual unas normas se fundan o derivan de otras, y se relacionan entre sí a través de relaciones de jerarquía y completitud.<sup>28</sup> Y en caso de contradicción entre normas de

<sup>27</sup> AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3º edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 292.

<sup>28</sup> Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3º edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 453.

diferentes gradas, prevalecen las normas y principios de "grado superior". Así, se logra la unidad del sistema jurídico. La Primera Constitución es la norma de grada superior de la cual derivan --o en la cual fundamentan su validez- la totalidad de las normas de un ordenamiento jurídico determinado.

### **- El Estado y el Derecho.**

La doctrina tradicional sostiene que el Estado es una institución de naturaleza totalmente distinta al Derecho. Así, considera al Estado como Poder o como unidad histórica y/o cultural, que tiene la potestad de crear el Derecho. El Estado crea el Derecho y se somete a él voluntariamente, quedando como "persona jurídica" obligada y facultada por el orden jurídico.

En cambio, para la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, la tesis es la situación contraria, Estado y Derecho son en esencia lo mismo: un orden coactivo de la conducta humana. De esta forma, el Estado es la personificación del orden jurídico nacional.<sup>29</sup>

### **- La pirámide jurídica de Kelsen: Constitución Nacional, normas generales y normas individuales.**

La Asamblea Constituyente cuando dicta la primer Constitución prevé el procedimiento para determinar que órgano, de qué forma y cómo se encuentra autorizado para dictar una nueva Constitución o para reformarla.

Por su parte, la Constitución vigente preverá el órgano competente y el procedimiento para dictar normas jurídicas generales (Poder Legislativo). También incluirá otras cláusulas constitucionales estableciendo los otros poderes del Estado (Poder Judicial y Poder Ejecutivo) y el tipo de normas que se encuentra autorizados a dictar (sentencias y actos administrativos). Además, a la par de las cláusulas comentadas, se regula la denominada parte dogmática, que incluye las normas de contenido material denominadas "Declaraciones, derechos y garantías".

---

<sup>29</sup> Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 296 y 297.

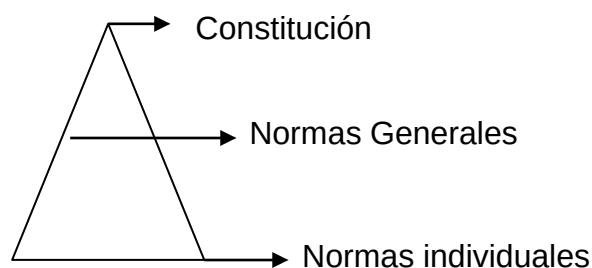
La creación de normas generales se encuentra sometida a la Constitución Nacional en un doble aspecto:

- a) Formal: porque debe realizarse mediante el órgano y el procedimiento allí determinado;
- b) Material: porque su contenido debe ajustarse a lo dispuesto en términos generales en la misma parte dogmática de la Constitución.

La norma general (la Ley) regula la sentencia judicial en un doble aspecto: formal y material. Por una parte, el juez aplica al sentenciar las leyes de forma, de atribución de jurisdicción y competencia, y organización del proceso; y, por la otra, aplica la ley de fondo que regula la relación jurídica sometida a su consideración.

Por último, la sentencia judicial o el acto administrativo son la norma individual del caso, llegando al fin de la cadena normativa. Son normas individuales de pura aplicación.<sup>30</sup>

De esta forma, Hans Kelsen explica la norma jurídica no aisladamente, sino en el marco de un complejo unitario denominado ordenamiento jurídico que se funda en el hecho que todas las normas del conjunto se derivan de una única norma suprema o fundamental.



---

<sup>30</sup> Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3ª edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 475 y siguientes.

### 3. Las ramas del Derecho: Derecho Público y Derecho Privado.

La distinción entre el Derecho Público y Derecho Privado nace en el Derecho Romano bajo el aforismo "*publicum jus est quod ad statum rei romanee spectat*" y "*privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet*", basándose la distinción en el interés protegido por el derecho. Así, el derecho público protegía el interés del Estado y la cosa pública, y el derecho privado protegía el interés de los particulares.

En la actualidad existen otros criterios de distinción basados en el tipo de la relación jurídica, el interés protegido o en la calidad del sujeto interviniente. También existe una corriente que niega directamente la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado.<sup>31</sup>



#### - Criterios de distinción:

- a) Tipo de la relación jurídica: según este criterio de distinción el derecho público es aquel que regula relaciones jurídicas de subordinación -justicia distributiva-, y el derecho privado es aquel que regula relaciones jurídicas de coordinación entre sujetos ubicados en situación de paridad -justicia conmutativa-.
- b) Interés protegido: este criterio de distinción se basa en los intereses cuya satisfacción el derecho procura. Así, si el interés jurídico protegido es el de los particulares, se está en el ámbito del derecho privado, y cuando el interés jurídico es el del Estado se está en el marco del derecho público.
- c) Calidad del sujeto de derecho: si la norma se refiere al Estado como poder público se está dentro del derecho público; en cambio, si trata de sujetos que obran desprovistos de todo carácter estatal es de derecho privado.

---

<sup>31</sup> Cfr. LLAMBÍAS, Jorge J.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, 16° ed. actualizada por Patricio Raffo Benegas, Ed. Perrot, Bs. As., 1995, pág. 42.

## **- Derecho Natural -iusnaturalismo- y Derecho Positivo -iuspositivismo-.**

El iusnaturalismo siempre ha estado en contraposición del iuspositivismo en el fundamento y contenido del concepto del Derecho. La diferencia fundamental en el contenido del fenómeno jurídico reside en que para el positivismo, el Derecho sólo comprende al conjunto de normas jurídicas vigentes en un determinado territorio. En cambio, para las corrientes del iusnaturalistas, además del derecho positivo, existe un Derecho Natural superior que el positivo debe reconocer y adecuarse a sus preceptos.

Asimismo, aún del iusnaturalismo existen dos corrientes donde varía el fundamento del Derecho Natural. Por un lado, está la corriente iusnaturalista de raíz teológica; y por el otro, esta la corriente iusnaturalista de raíz profana o racionalista.



**- Corriente del Positivismo Jurídico**  $\Rightarrow$  **Derecho Positivo**

**- Corriente del iusnaturalismo**

$\downarrow$

**Derecho Positivo + Derecho Natural**

$\nearrow$  **De raíz teológica**

$\searrow$  **De raíz profana o racionalista**

### **- El Positivismo Jurídico.**

La tesis central del positivismo es que el Derecho sólo está comprendido por las normas o reglas jurídicas que han sido sancionadas por el hombre, sin encontrarse sometido o sujeto a ningún otro tipo de Derecho superior. De esta forma, las normas jurídicas nacen de actos humanos de voluntad y no de cosas ni del conocimiento de

cosas. El positivismo realiza una identificación del derecho con la ley, pero entendiendo el término en su sentido material, que incluye no sólo a las leyes generales sino también a las normas constitucionales.<sup>32</sup>

#### **- El iusnaturalismo de raíz teológica.**

Esta tesis sostiene que el derecho no está constituido sólo por las normas jurídicas sancionadas por el Hombre o por sus Autoridades, sino que hay un Derecho Natural cognoscible superior, que vale como tal aunque no se lo haya reconocido o receptado por el Hombre. Es un valor que se encuentra presente en todas las épocas y en todos los pueblos y que es superior a las estructuras políticas y económicas.

Esta juridicidad indisponible, *per se* o *proprio vigore* recibe una fundamentación o nombres muy diversos: en Roma era denominado “*ius naturale*”, el escolástico “derecho o ley natural”, Dworkin lo fundamenta en los “principios jurídicos o *principles*”, Carlos Nino en “moral rights” o “derechos humanos”, Alexy como “umbral de injusticia o injusticia extrema”, Jhon Finnis como “bienes humanos básicos” o Villey en el término “justicia”.

Para esta corriente, el Derecho Positivo es un conjunto de normas fundamentales dictadas por el Estado para el cumplimiento de sus fines, pero estas normas, para su validez, no pueden desconocer los principios y valores fundamentales de carácter universal e inmutable que provienen del Derecho Natural.

#### **- El iusnaturalismo profano o racionalista.**

Esta corriente del pensamiento trato de encontrar un concepto unitario de Derecho Natural universal y de validez imperecedera, aceptado por todos los hombres sin importar sus ideas religiosas. Nace a partir del racionalismo de los siglos XVI y XVII, donde se resalta la autonomía e independencia de la razón humana frente a la razón teológica. De esta forma cambia el fundamento del Derecho Natural dado hasta entonces por el iusnaturalismo de raíz teológica basado en la Ley Eterna, por un fundamento

---

<sup>32</sup> Cfr. GUASTINI, Ricardo; “Derecho dúctil, Derecho incierto”, en Anuario de Filosofía del Derecho XIII, 1996.



basado en la misma naturaleza racional del hombre: la razón, que es por igual a todo género humano.<sup>33</sup>

El iusnaturalismo racionalista sostiene que las relaciones sociales se rigen por leyes naturales que forman el Derecho Natural. Este iusnaturalismo defiende y postula un Derecho basado en la existencia de normas generales, abstractas y eternas que surgen de la razón del Hombre, sobre las cuales debe descansar todo sistema de derecho positivo para ser válido y obligatorio. Estas leyes naturales pueden ser formuladas y conceptuadas por el hombre por su sola razón, con precisión y validez universal similar a las leyes de la naturaleza. Defienden la utilización del método matemático, único capaz de proporcionar la claridad y evidencia que exige la verdad racional, a los efectos de extraerse las leyes del obrar humano con toda precisión, creando un nuevo sistema jurídico.<sup>34</sup> Entre sus máximos representantes se pueden mencionar a Hugo Grocio, Samuel Pufendorf (1632-1694), C. Tomasio y C. Wolf.

## BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

### OBLIGATORIA

El material de estudio.

### COMPLEMENTARIA

- AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999.
- BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, Agustín; Filosofía del Derecho, Ed. Porrúa, México, 200.
- BORDA, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 1999.

---

<sup>33</sup> Cfr. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio; y FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio (Directores); Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo I - Transito a la Modernidad (s. XVI y XVII), 1° reimpresión corregida y ampliada, 2003, pág. 575 y 576.

<sup>34</sup> FUENTES LÓPEZ, Carlos; El Racionalismo Jurídico, 1° ed., Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, pág. 135.

- COSSIO, Carlos; La Teoría Ecológica del Derecho y el concepto jurídico de libertad; Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1964.
- COVIELLO, Pedro J., "El control judicial de la discrecionalidad administrativa", en "Control de la Administración Pública", ediciones RAP, pág. 627, 642.
- DEL VECCHIO, G., Filosofía del Derecho, Tomo I, Ed. Bosch, Barcelona, 1936, pág. 2, 396, 403 y 412.
- DEL VECCHIO, Giorgio; *Los Principios Generales del Derecho*, traducción de Juan Ossorio Morales, Librería Bosch, Barcelona, año 1933, págs. 6 y 7.
- DWORKIN, Ronald; Los derechos en serio, traducción de Marta Guastavino, 5º reimpresión, Ed. Ariel S.A., Barcelona, año 2002.
- FERRATER MORA, José; Diccionario de Filosofía, 5ª ed., Ed. Sudamericana, Bs. As., Tomo I, 1964.
- FUENTES LÓPEZ, Carlos; El Racionalismo Jurídico, 1º ed., Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003.
- GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 7º ed., Ed. Civitas, Madrid, 1995.
- GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo; Filosofía del Derecho, 17º ed., Ed. Porrúa, México, 2009.
- GUASTINI, Ricardo; "Derecho dúctil, Derecho incierto", en Anuario de Filosofía del Derecho XIII, 1996.
- HART, H.L.A.; El Concepto de Derecho, traducción de Genaro R. CARRIO, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1977.
- KANT, Immanuel; Metafísica de las costumbres - Introducción a la doctrina del Derecho, Apartado B, BI, pág. 230.
- KELSEN, Hans; General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945; traducción de E. GARCÍA MAYNEZ, Teoría General del Derecho y del Estado, Ed. UNAM, México, 1979.
- KELSEN, Hans; Teoría General del Estado, traducción de Luis LEGAZ LACAMBRA, Ed. Nacional, México, 1965.
- KELSEN, Hans; Teoría Pura del Derecho, Traducción 2º ed. del alemán Roberto J. Vernengo, 2º reimpresión, México, 1982.
- LLAMBÍAS, Jorge J.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, 16º ed. actualizada por Patricio Raffo Benegas, Ed. Perrot, Bs. As., 1995.
- PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio; y FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio (Directores); Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo I - Transito a la Modernidad (s. XVI y XVII), 1º reimpresión corregida y ampliada, 2003.
- VIGO (h), Rodolfo; Los principios jurídicos, Depalma, Bs. As., 2000.

- VIGO (h), Rodolfo; Visión Crítica de la Historia de la Filosofía del Derecho, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 1984.